

【事例】に関するアからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事 例】

甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①)

乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博することを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。(②)

乙は、同月5日、高額収入が得られる旨をうたう求人サイトに応募したところ、同サイトを運営していた丁から、不正に入手したクレジットカードの名義人Aを装って電子マネーの購入手続をするよう依頼されてこれに応じ、インターネットを介して、Aの氏名やカード番号等の情報をクレジットカード決済代行会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクにAが10万円相当の電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作成して同電子マネーの利用権を取得した。(③)

丁は、不特定多数の者に電話をかけ、真実は違約金を支払う必要がないのに、これを支払う必要がある旨のうそを告げ、某所に現金を送付させて詐取することを繰り返していた。丁は、乙の応募に先立つ同月4日、Bに電話をかけ、前同様のうそを告げ、現金を某所に送付するよう指示した。Bは、うそを見破って警察官に通報したところ、警察官から丁の上記指示に従ったふりをするよう依頼され、同月5日、模造紙幣が入った荷物を某所に発送した。乙は、同月6日、丁から、上記指示内容について説明を受けるとともに上記荷物を受領して丁に届けるよう依頼され、同荷物が詐欺の被害金であると認識した上でこれに応じ、いわゆるだまされたふり作戦の開始を認識しないまま某所で宅配業者から同荷物を受領したが、その場で警察官に逮捕された。(④)

丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。(⑤)

【記 述】

ア. ①につき、甲は、公序良俗に反する無効な行為を原因として乙に債務を負担させているので、甲に詐欺罪は成立しない。

イ. ②につき、正犯である乙に単純賭博罪が成立するにすぎないので、丙が賭博の常習者であったとしても、丙に単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。

ウ. ③につき、乙が上記電子計算機に送信したAの氏名やカード番号等はいずれも真正なものであり、「虚偽の情報」に当たらないので、乙及び丁に電子計算機使用詐欺罪の共同正犯は成立しない。

エ. ④につき、乙は、だまされたふり作戦の開始後に加功しているので、乙の加功前になされた欺罔行為を含む詐欺未遂罪の共同正犯は成立しない。

オ. ⑤につき、犯人が他人を教唆して自己を隠避させることは定型的に期待可能性がないので、丁に犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。

No445

総合事例

正答率

48%

共通R7-20

正解

ア 2

イ 2

ウ 2

エ 2

オ 2

ア 誤っている

最決昭43.10.24は、暴力団員が詐欺賭博の方法で賭客となった者を欺罔し、寺銭及び賭銭名義のもと、金員を支払うべき債務を負担させた事案において、2項詐欺既遂罪の成立を認めている。したがって、本記述では、甲に2項詐欺罪が成立する。

イ 誤っている

大判大3.5.18は、賭博の常習者が非常習者の賭博を幫助した事案につき、常習者の幫助行為において常習性が発現した場合には、65条2項により常習賭博罪の幫助犯が成立するとしている。かかる判例は、不真正身分犯においては身分の有無に応じて個別的に刑を科するというのが65条2項の趣旨であるから、この場合も65条2項が適用されるという見解を採っていると解される。したがって、賭博の常習者である丙が非常習者である乙に賭博を教唆した場合、丙に常習賭博罪の教唆犯が成立する。

ウ 誤っている

最決平18.2.14（百選Ⅱ59事件）は、「クレジットカードの名義人による電子マネーの購入の申込みがないにもかかわらず、本件電子計算機に同カードに係る番号等を入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え、名義人本人がこれを購入したとする財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作り、電子マネーの利用権を取得して財産上不法の利益を得たものというべきであるから、被告人につき、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判断は正当である」としている。したがって、乙が上記電子計算機に送信したAの氏名やカード番号等はいずれも真正なものであるとしても「虚偽の情報」に当たり、「不実の電磁的記録を作ったといえるから、乙及び丁に電子計算機使用詐欺罪の共同正犯が成立する。

エ 誤っている

最決平29.12.11（百選Ⅰ82事件）は、「被告人は、本件詐欺につき、共犯者による本件欺罔行為がされた後、だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに、共犯者らと共に共謀の上、本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している。そうすると、だまされたふり作戦の開始いかににかかわらず、被告人は、その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき、詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負う」としている。したがって、乙は自身の加功前になされた欺罔行為を含む詐欺未遂罪の共同正犯が成立する。

オ 誤っている

大判昭8.10.18、最決昭40.2.26、最決昭60.7.3。犯人が他人を教唆して自己を蔵匿・隠避させた場合に、同罪の教唆犯が成立するかについて、判例は、一貫して教唆犯の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、犯人自身の隠避行為が罪とならないのは、これを罰することが刑事訴訟における被告人の防御の地位と相容れないからであり、他人を教唆してまでその目的を遂げようとするとは、もはや法の放任する防御の範囲を逸脱しているということを挙げていいる。したがって、丁に犯人隠避罪の教唆犯が成立する。

